

1500021-72.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... dos réus apenas pelo crime de tráfico de drogas.

A Defesa de Victor pugnou pela absolvição do acusado da prática do crime de associação para o tráfico e pela fixação da pena no mínimo legal.

A Defesa de Leandro pugnou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal (fls. 227/239).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500021-72.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-72.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2001704/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22249531 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 26/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2001704 - DEL.POL.SALTO, 26/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR RAFAEL DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

VICTOR RAFAEL DOS SANTOS e LEANDRO CUNHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, ambos c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, (1) em dia e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até 03 de janeiro de 2022, por volta das 19h48min, na rua José de Oliveira Gilardi, nº 216, São João, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, associaram-se com o fim de praticarem,

reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, bem como, (2) na data e local indicados, agindo em concurso, previamente associados e em unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 249 porções de cocaína, com peso aproximado de 362,7g (trezentos e sessenta e dois gramas e sete decigramas); b) 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso aproximado de 28,8g (vinte e oito gramas e oito decigramas); c) 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 19,95g (dezenove gramas e noventa e cinco centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que os réus guardavam e dividiam grandes quantidades de drogas, especialmente "cocaína", e, juntos, ainda promoviam a venda a terceiros no bairro São João. Na noite de 03 de janeiro de 2022, os acusados estavam sentados na calçada da Rua José de Oliveira Gilardi, manuseando e separando centenas de porções de cocaína destinadas ao tráfico, sobre uma blusa de moletom. Ocorreu que, guardas municipais realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram os réus dividindo os entorpecentes e decidiram pela abordagem. Os acusados, ao notarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, cada um correndo para um lado. Com o apoio de outra equipe, os agentes policiais lograram êxito em detê-los na Rua Vesúvio. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os indiciados. Porém, com cada um foi apreendido um telefone celular e o réu Victor ainda trazia consigo o valor de R\$290,00 (duzentos e noventa reais). Ato contínuo, os guardas municipais recolheram 326 (trezentas e vinte e seis) porções de cocaína sobre a blusa de moletom estendida na calçada, as quais estavam sendo manuseadas pelos réus. Com isso, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 120/130 e 142/151). A denúncia foi recebida e determinada a citação (fls. 160/162).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da acusação. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus apenas pelo crime de tráfico de drogas.

A Defesa de Victor pugnou pela absolvição do acusado da prática do crime de associação para o tráfico e pela fixação da pena no mínimo legal.

A Defesa de Leandro pugnou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal (fls. 227/239).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09) e pelo laudo de exame químico toxicológico, com resultado positivo para cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião dos fatos (fls. 213/215).

A autoria também restou comprovada, especialmente pela prova oral dos autos.

Victor admitiu a prática delituosa. Declarou que tinha recebido dinheiro do serviço e gastou. Caiu no vício de drogas e teve que vender drogas. Comunicou-se com o responsável pelo ponto de tráfico para poder usar drogas. Estava servindo clientes. Avistou Leandro, a uns 10 a 30 metros, tendo ele perguntado se tinha maconha. Falou que não tinha. O cliente ao lado dele o alertou da presença da ROMU. Dispensou as drogas e saiu correndo, junto com 4 indivíduos e Leandro. Tinha 326 pinos. Leandro estava indo comprar. Pegou as drogas naquela noite. Ia vender das 7h da noite as 7h da manhã. Os outros indivíduos conseguiram fugir. Não assumiu na hora a traficância. Os guardas lhe bateram e disseram que, como conheciam Leandro e não os conheciam, ele teria que falar que pertenciam a Leandro senão, pelo tanto de droga que tinha, iam na sua casa e prejudicariam familiares. Trazia R\$290,00.

Leandro negou a prática delituosa. Declarou que foi comprar maconha. Não sabia que era Victor que estava vendendo, vindo a saber no CDP. No dia, perguntou de longe se tinha maconha para vender. Ele falou que não tinha. Viu a ROMU vindo e os rapazes correndo, razão pela qual correu também. Os guardas só pegaram Victor e ele. Os outros escaparam. Tinha R\$10,00 na mão para comprar maconha, mas perdeu quando correu. Não estava manuseando as drogas. Nunca tinha comprado com Victor. Era a

primeira vez que foi comprar no São João. Comprava no União. Conhecia os guardas municipais, que, em uma prisão anterior, teriam participado da ocorrência, na qual foi pego comprando droga, tendo o cara corrido, mas acabou sendo preso no lugar. Ficou 3 meses e saiu.

Não obstante o direito à autodefesa permitir aos acusados trazerem ao processo as suas versões dos fatos, no presente caso, a tentativa de Victor de isentar Leandro e a negativa deste não se coadunam com a prova coligida.

Isso porque as declarações dos guardas municipais são suficientes para o deslinde condenatório.

A testemunha Diego declarou que estavam em patrulhamento no bairro São João, em área de lazer utilizada como ponto de venda de drogas. Visualizaram 2 indivíduos agachados na calçada mexendo em algo. Quando viram a viatura correram. Correu atrás, conseguindo detê-los com apoio de outra equipe. Foram identificados como Leandro e Victor. Em revista pessoal, com Leandro foi encontrado apenas celular. Com Victor R\$290,00. Questionados, Leandro disse que ia comprar maconha de Victor e quando viu a viatura correu. Victor disse que ia comprar cocaína de Leandro, tendo este colocado as drogas na calçada para escolher o tipo. Retornou ao local, onde tinha blusa com 326 porções de cocaína, sendo 249 pinos, 49 em saquinhos e 28 em ziploc. Foi dada voz de prisão e conduzidos ao plantão policial. Ambos eram conhecidos no meio policial. Os dois estavam agachados um em frente ao outro mexendo em algo na calçada.

No mesmo sentido, a testemunha Eduardo declarou que estavam em patrulhamento em área de lazer, local conhecido ponto de venda de drogas. Avistou 2 indivíduos agachados manuseando algo. Com a aproximação da viatura, eles se evadiram em sentido área de lazer onde as crianças brincavam. Morais desembarcou e acompanhou. Ficou no local e verificou que havia uma blusa estendida na calçada com 326 porções de drogas, sendo 249 pinos, 49 em saquinhos e 28 em ziploc. Morais, com o apoio de outra viatura, conseguiu abordar. Com Victor foi encontrado R\$290,00. Com Leandro nada foi encontrado. Leandro informou que teria ido comprar maconha de Victor. Victor disse que tinha ido comprar cocaína de Leandro, o qual teria espalhado as porções no chão para escolher. Foi dada voz de prisão e conduzidos para delegacia. Via Victor com menos frequência, mas tinha conhecimento de ocorrência de tráfico no bairro União. Leandro era visto em locais de tráfico com grande frequência, quase diariamente. Não tinha notícia de que traficavam juntos.

Ressalva-se que o mero fato de os guardas municipais terem participado da prisão dos réus, por si só, não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que está em plena harmonia com as demais provas dos autos. Não há indicativo acerca eventual acusação injusta dos guardas contra os réus.

No mais, descabe se falar em ilegalidade do flagrante e de prova ilícita. As condutas atribuídas aos acusados são de trazer consigo, guardar as drogas. Trata-se de crimes permanentes, nos quais se entende o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (artigo 303 do CPP). Logo, como qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, o que ocorreu no caso, visto que a permanência não havia cessado, não há se falar em prova ilícita, visto que os guardas municipais compõem, obviamente, o povo.

Além disso, a abordagem e consequente busca pessoal se deu em razão de os acusados estarem manuseando as drogas na rua, em cima de um moletom, denotando fundada razão.

Assim, pelas circunstâncias em que o flagrante se deu, denota-se a prática de tráfico ilícito de entorpecentes: as drogas foram encontradas individualmente embaladas; as drogas estavam prontas para o comércio; a quantidade de drogas apreendidas demonstram que as substâncias não se destinavam ao consumo pessoal; os guardas viram os réus manuseando as drogas.

O crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Por todo o exposto, as circunstâncias dos fatos, que restaram comprovadas pela prova obtida nos autos, demonstram a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes cometidos pelos réus, sendo a condenação medida de rigor.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não restou demonstrada sua ocorrência. O fato de os acusados terem sido presos na mesma ocasião não comprova que possuíam unidade de vontades ou ações para a prática do crime, ainda que eventualmente, tampouco estabilidade e permanência. Passo à dosagem individual das penas.

I) Réu Victor Rafael:

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta bons antecedentes criminais, mas foi preso com grande quantidade de drogas (mais de 300 porções de cocaína), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (fl. 30 - processo 1501640-74.2019.8.26.0526, com sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas transitada em julgado para a defesa em 05/06/2020). Não há se falar em incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia causada pelo Covid-19 para praticar o delito. Por outro lado, o acusado contava com menos de 21 anos na data dos fatos e confessou a prática delituosa. Assim, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo a pena-provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diante da reincidência do acusado. Assim, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

II) Réu Leandro

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta bons antecedentes criminais, considerando que é tecnicamente primário, pois não há notícia de trânsito em julgado da sentença penal condenatória antes dos fatos (fl. 35 - processo 1500658-91.2020.8.26.0569).

Todavia, foi preso com grande quantidade de drogas (mais de 300 porções de cocaína), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Não há se falar em incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia causada pelo Covid-19 para praticar o delito. Não há atenuantes. Assim, fixo a pena-provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento. No mais, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena definitiva 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para:

1) ABSOLVER Victor Rafael dos Santos e Leandro Cunha da imputação contida no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal;

2) CONDENAR Victor Rafael dos Santos pela prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Tendo em vista que o delito de tráfico imputado à acusada é equiparado pela lei a crime hediondo, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na

hipótese.

Não cumprido o requisito objetivo (40% de cumprimento da pena, se o apenado for reincidente não específico e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte (art. 112, V da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 e Temas 1169 do STF e 1084 do STJ)), o que equivale a 2 anos), inviável a análise de que trata o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão do réu, haja vista a gravidade do delito praticado, bem como a prisão durante todo o transcorrer do processo. Ademais, subsistem os requisitos da prisão cautelar, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, já que o acusado foi detido novamente pela prática de crime de tráfico de drogas, sendo flagrado com mais de 300 porções de cocaína, denotando perigo se em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, servindo a presente como ofício ao Diretor do estabelecimento prisional.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

3) CONDENAR Leandro Cunha pela prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição.

Cumprido o requisito objetivo (16% de cumprimento da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, I da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019), o que equivale a 3 meses e 10 dias), fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Diante do regime inicial imposto, do tempo decorrido desde a data da prisão (31/01/2022) e não se vislumbrando presentes os motivos ensejadores para manutenção da prisão preventiva, faculto ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls. 08), já que não comprovada a origem lícita e, ao que tudo indica, era proveniente de ilícito penal. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA